

1500637-18.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500637-18.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500637-18.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2065748/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 23491356 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 27/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2065748 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2065748/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Gavioli Silveira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

DIEGO GAVIOLI SILVEIRA, vulgo "Di" ou "Geleia", e MARCEL CAMARGO SILVEIRA, vulgo "d", qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em data e horário indeterminados, porém antes de 09 de março de 2022 e até essa data inclusive, por volta das 06h30min, na Rua Marcelo Camargo, nº 91, Jardim Mercedes, nesta cidade e comarca de Limeira, os acusados Diego e Marcel associaram-se, inclusive, com outros indivíduos ainda não identificados, e com outros indivíduos identificados e investigados em outros feitos, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, tráfico ilícito de drogas.

Consta ainda que, em 09 de março de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Marcelo Camargo, nº 91, Jardim Mercedes, nesta cidade e comarca de Limeira, Diego e Marcelo, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, tinham em depósito e guardavam, com intuito de comercialização ilícita, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, uma porção média de maconha pesando 0,46 gramas, bem como três cigarros artesanais da mesma droga, pesando 0,47 gramas, além de duas porções de haxixe, pesando 38,85 gramas, conforme auto de constatação e laudo de constatação.

Segundo o apurado, em datas indeterminadas, mas antes de 09 de março de 2022 e nessa data inclusive, os denunciados, os quais são, respectivamente, filho e pai, associaram-se de forma permanente e estável, inclusive com outras pessoas ainda não identificadas e com outros investigados em outros procedimentos, a fim de praticarem o delito de tráfico de drogas na cidade de Limeira. Nesse contexto, Marcel passou a negociar com terceiras pessoas o fornecimento de maconha, especialmente por meio do aplicativo Whatsapp, enquanto Diego também passou a negociar tal tóxico e haxixe para a comercialização de terceiros.

Posteriormente, em investigação a outras pessoas associadas para o tráfico ilícito de drogas, policiais civis identificaram conversas via aplicativo Messenger do site de relacionamentos da internet denominado Facebook envolvendo a negociação de maconha originária da Colômbia. Em outros diálogos entre tais pessoais, restou apurado que Marcel estocava e fornecia o referido tipo de maconha. Assim, por meio do aplicativo Whatsapp, comentou-se entre tais pessoas, dentre os quais Gabriel Farnochi Freire, investigado em outro feito, que seria dado um salve no “d”, para verificar se ele ainda tinha 2 kg no “pente”, a fim de “fechar mais um”, diante do que um dos interlocutores respondeu “demoro”. Portanto, negociou-se 1 kg do mencionado tóxico, sendo certo que Marcel, vulgo “d”, figurou como espécie de sócio nas transações ilícitas, pois restou evidente a pretensão de adquirir dele 2 kg de maconha e agregar mais 1 kg da mesma droga.

Em face de todos esses diálogos envolvendo Diego e seu genitor Marcel, houve representação da Autoridade Policial e deferimento de mandado judicial de busca e apreensão.

Na ocasião do cumprimento, verificou-se que ambos os denunciados tinham em depósito e guardavam porções de maconha e haxixe, para a venda e consumo a terceiros.

Assim, policiais civis e guardas civis municipais realizaram operação especial conjunta e se dirigiram à residência de ambos os réus, onde foram recebidos por Marcel. Em continuidade à diligência, um dos policiais civis localizou sobre uma escrivaninha, no quarto de Diego, dois recipientes de vidro, um deles contendo uma porção graúda de haxixe e, no outro, uma porção menor de maconha. Ainda na mesma escrivaninha, em um pequeno recipiente hexagonal de plástico amarelo havia três cigarros artesanais de maconha, um dichavador, uma pequena balança digital e uma carteira contendo duzentos reais em dinheiro.

Mediante autorização expressa e escrita, ambos os denunciados consentiram na exibição e análise as mensagens contidas em seus telefones celulares, mediante as quais se apurou atos de inequívoca associação entre ambos para a prática do tráfico ilícito de drogas, envolvendo, inclusive, outros comparsas investigados em outros feitos. Além disso, verificou-se, também, intensa comercialização de maconha e haxixe, diretamente por Diego, ocasião em que ele foi preso em flagrante delito.

Os fatos ocorreram durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, devendo incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 175/176 e 177/186).

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022 (fls. 217/218).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório dos réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 262/274) e da Defesa dos réus Marcel (fls. 276/283) e Diego (fls. 283/294).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 21/23), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo pericial com resultado positivo para maconha e haxixe (fls. 34/37 e 133/135), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa unicamente quanto ao acusado Diego, não havendo provas seguras quanto ao corréu Marcel.

Em Juízo, o acusado Diego disse que tem 24 anos. Trabalha no Cartório de Registro de Imóveis. Formou na FATEC, iria colar grau. Estava dormindo e foi acordado com os policiais no seu quarto. A maconha estava no seu quarto e ficava guardada. Mostrou onde estavam as drogas. Não é traficante. Faz uso conjunto de drogas. Entende que certas mensagens podem trazer uma visão errada quanto à sua pessoa. Mora com seus pais. Sempre usou drogas nos últimos dez anos. Juntava amigos para fazer uso conjunto de entorpecentes. Não gostava de ir até as biqueiras. As drogas eram divididas no grupo de colegas. Faziam uso. Não precisa vender drogas. Era dependente. Havia um grupo montado entre eles, não queria frequentar biqueiras. Ninguém é traficante no grupo. Esse grupo é grande, entre quinze a vinte pessoas fazem parte. Não tem alguém que comanda o grupo. Dividia entre os integrantes o trabalho de ir buscar drogas. Já faz parte do grupo há mais de um ano. Foi colocado por um tal de "Di". Tem apelido de "Di" ou "D". Já teve problemas com a justiça criminal em 2019. Usou o celular do seu pai e conversou com amigos naquela época. O celular do menino foi investigado porque ele brigou com um policial civil. Seu pai é uma pessoa honesta e íntegra. Conhece Gabriel e não tem mais amizade com ele. Frequentava muito a casa de Gabriel. As conversas são de março de 2019. Tinha dinheiro na sua carteira e era decorrente do seu salário. Nega a figura do tráfico, nunca revendeu maconha. Não tirava lucro disso. Não está associado a traficantes locais. Costumava pedir a uns amigos para buscar as drogas e pagava a gasolina, os traficantes traziam até ele. Enrolava o cigarro e fazia uso. Depois da sua prisão, chamou Gabriel e queria conversar sobre o ocorrido. Identificou-se como "D" nessa conversa. Seu pai informou a Gabriel a respeito da prisão do filho. Seu celular ficou apreendido em Campinas naquela época, estava sem telefone. Ficou usando o telefone do seu genitor por uma semana. Muitas pessoas têm apelido "D", nunca teve quantia grande de entorpecentes em seu poder. Nunca passou de 50 gramas, não sabe quem vende uma quantia tão alta, não é vinculado a ele essa mensagem. Nunca fez entrega de drogas. A pessoa do Citroen de cor branca do Mister Titas não sabe quem é. Não comercializava haxixe. Carlinhos é um colega dele e faz uso junto com eles. Repassou o valor que os traficantes passaram a ele para comprarem entorpecentes a

fim deles fazerem uso de drogas em conjunto. A qualidade das drogas era melhor, a maconha de biqueira é ruim. Repassava o valor que o traficante fornecia. Não sabe explicar porque todas essas pessoas se dirigiam a ele para comprar drogas. Os traficantes o procuravam, falavam que iriam chegar drogas e haveria rateio entre os membros do grupo. Não soube explicar porque não foram colocados os diálogos do grupo. O pai dele nunca participou de grupo de drogas (mídia).

Em Juízo, o acusado Marcel contou que tem 50 anos. É supervisor de ensino da prefeitura de Limeira e atua junto com a procuradora municipal. No período da noite dá aulas de português há 30 anos. É escritor. Ajuda na coordenação do Programa Escola Cidadã. Estava dormindo com a sua esposa. Tocou a campainha. A polícia estava no portão. Abriu a porta. Viu que havia um mandado contra ele. Ficou muito nervoso. Fabiana é sua esposa e o acalmou. As drogas foram encontradas no quarto de Diego. Seu filho foi preso em flagrante. Foi com seu carro até a delegacia. Entregou seu telefone celular. Deu autorização para mexerem no aparelho. Ficou sabendo que foi relacionado com o "D". Seu filho fez uso do seu celular. Não tem qualquer processo contra ele, nunca sofreu sequer processo administrativo. Dá para ver nas mensagens que são duas pessoas, contou a Gabriel que seu filho foi preso. Nunca teve envolvimento com o tráfico e com associação. Nada sabe a respeito de grupo envolvendo usuários de drogas e seu filho. Desconfiava que seu filho fazia uso de entorpecentes. Nunca tinha visto aquela balança encontrada no quarto do seu parente. Imaginava que seu filho fumava em festas e churrascos. Coibia seu filho de fazer uso de drogas na sua casa. Gabriel estudou com Diego e frequentava a casa deles. Nunca viu transações de drogas envolvendo seu filho e amigos. Já sentiu cheiro de maconha no veículo de Diego. Nunca usou maconha e nunca comercializou, ficou desesperado no dia da prisão e cumprimento do mandado, jamais imaginava que seu filho mexia com tantas drogas (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, a qual incrimina tão somente o acusado Diego.

O guarda civil municipal Moreira Junior contou que a delegacia especializada solicitou apoio no mandado de busca e apreensão numa residência. O mandado constava o nome de Marcel. Diego é filho dele. Após ciência, entraram na residência com os policiais Ricardo e Jane. Marcel acordou o filho Diego. Foi com o policial Ricardo e na mesa de computador do quarto de Diego encontraram entorpecentes, era haxixe e um pedaço de maconha. Diego disse que era dele e seria para fins de uso pessoal. Ele disse que adquiria em grande quantidade. O pai de Diego nada disse. Diego assumiu ser o dono daquelas drogas. Não conhece a parte da investigação, deram o apoio no cumprimento do mandado. As drogas foram encontradas no quarto de Diego. Não acompanhou a revista no quarto do Marcel, só ficou no quarto de Diego. Não se recorda de ter sido localizado algo no quarto de Marcel. Não teve qualquer resistência de Marcel (mídia).

O policial civil Ricardo Alfredo Coelho contou que foram cumprir um mandado de busca em razão da apreensão de telefone celular de um traficante chamado Gabriel. Foram no endereço da Rua Marcelo Camargo. No quarto de Diego encontraram porções de maconha, haxixe, balança digital e outros petrechos. Foram autorizados que olhassem os telefones celulares. Diego foi conduzido ao distrito policial, Marcel os acompanhou até o distrito policial. Houve prisão em flagrante de Diego. Houve uma investigação pelo setor de inteligência. Foi o policial Alexandre que conduziu essa investigação. Gabriel entrou em contato com os réus por telefone celular. Diego deu autorização e no celular dele havia conversas comprometedoras. Marcel ficou muito nervoso e alegou que o filho Diego era usuário, ele não sabia que o filho traficava. Encontraram duzentos reais numa carteira. Os entorpecentes e dinheiro estavam no quarto de Diego. Vieram mais equipes, ficou no quarto de Diego. A policial Jane foi no quarto de Marcel. Não se recorda do telefone celular de Marcel, Diego autorizou o acesso ao seu telefone celular. Marcel foi liberado na delegacia, ele não foi indiciado, o caso envolvia mais o acusado Diego (mídia).

A policial civil Jane Aparecida da Costa disse que as investigações prévias foram feitas pelo investigador Alexandre. Um telefone celular de Gabriel foi apreendido. Foi feito um relatório desse telefone. Diego e Marcel foram mencionados nesse telefone. No local do cumprimento de mandado de busca e apreensão foi junto com o policial Ricardo e mais guardas civis municipais. O acusado Marcel ficou nervoso com a presença da polícia. No quarto de Diego localizaram drogas, dinheiro, balança de precisão e dois telefones celulares. O restante da casa não tinha mais nada ligado ao tráfico e nem indícios. Pessoas foram identificadas e o mandado de busca foi solicitado. O alvo do mandado de busca era Diego, Marcel é pessoa do bem, há uma família no local. Marcel sabia que o filho fazia uso de drogas. Foi autorizado por escrito o acesso aos telefones celulares. No telefone do Marcel não tinha nada de incriminador. De Diego havia conversas comprometedoras e relacionadas ao tráfico. Não foi ela que verificou o aparelho. O delegado liberou Marcel, não havia nada contra ele, o caso envolvia apenas Diego (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais civis e guardas civis municipais neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os réus.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A testemunha Jacqueline de Fátima Duarte Veiga e Souza é diretora de escola do acusado Marcel. Conhece o corréu Diego. Conhece Marcel há dez anos. Ele é um profissional comprometido e respeitado. Ele é professor da escola. Considera-o um bom professor e muito atuante, nunca falta e é muito participativo. Desconhece qualquer apelido de Marcel. Sabe que Marcel já comentou a respeito do envolvimento do filho Diego com o tráfico, Marcel ficou muito chateado com a prisão. Marcel exerce cargo público como supervisor escolar. É trabalho concursado (mídia).

A informante Franselma de Cássia da Silva Bezerra conhece Marcel há onze anos, confirmou que ele é pessoa íntegra, trabalha na Secretaria da Educação de Limeira e dá aulas à noite. É um patrão muito bom. Nunca verificou movimentação estranha na

casa dele. Diego fazia faculdade quando da sua prisão. Já sentiu cheiro de maconha na casa. Diego nunca comentou a respeito de uso de drogas. Marcel nunca se envolveu com entorpecentes (mídia).

A testemunha Rosana Cristina Tofoli da Silva trabalhou com o acusado Marcel. Conhece ele desde 2008. Marcel ingressou por concurso. Ela aposentou-se em 2020 e sempre trabalhou perto de Marcel. Sabe que Marcel é professor estadual e a conduta dele sempre foi pautada na legislação. Gostava muito da atuação de Marcel, ele sempre foi um funcionário exemplar. Marcel já reclamou da conduta do filho Diego, o uso de entorpecentes por parte do filho o preocupava. Sabe que Marcel e a esposa sempre cuidavam do filho Diego. Marcel tem apelido de "Ma", na família ele é conhecido como "Cel" (mídia).

A testemunha Josemari Cristina Parizzi Gonzaga disse que o acusado Marcel foi seu professor no magistério, assim como suas irmãs. Tem relação próxima com ele. Marcel sempre foi um professor muito querido, já o conhece de longa data. Marcel era seu supervisor de serviço na prefeitura. Desde 2012 até hoje ela trabalha com o acusado, fazem parte de diversas comissões municipais, é uma vida de trabalho que tem ao lado dele e da esposa. Marcel tem apelido de "Ma" e a esposa o chama de "Cel". Marcel já reclamou do filho Diego fazer uso de drogas, era uso de maconha. Os pais de Diego são muito honestos. Marcel tinha orgulho do filho Diego, mas temia que o uso de drogas o atrapalhasse. Marcel era respeitado no local de trabalho. Não acredita no envolvimento do Marcel com o tráfico de drogas, é impossível isso. Confiava em Marcel. Tem conhecimento que Diego respondeu a um processo criminal. Marcel comentou e ficou arrasado, fizeram até grupo de oração (mídia).

O informante Lucas Roberto Olivieri contou que é amigo íntimo de Diego. Sabe que Diego faz uso de maconha. Os amigos compravam juntos e dividiam as drogas entre eles. Já participou da compra. Cada um dava uma quantia em dinheiro, quando chegava eles dividiam as drogas em porções menores. Diego não realizava o tráfico, as drogas eram divididas entre os mais próximos. Cada um dava dinheiro, não era muito frequente ele fazer as compras, não se envolvia muito. Não sabe quem é o fornecedor. Não era ele quem comprava. Não sabe se era Diego a pessoa que comprava (mídia).

O informante Gabriel Evangelista Pereira contou que é amigo íntimo de Diego. Frequentava a casa de Diego, conhece os pais dele. Marcel não tinha apelido. Diego tem apelido de "D". Chamava o pai dele de Senhor Marcel. Compravam drogas em conjunto, tinham um grupo, davam dinheiro e vinha maconha. Cada um ficava com sua parte. Faziam isso para não irem nas biqueiras. Alguém iria buscar e era feita a divisão da droga. Participou dessas compras. Só envolvia o pessoal do grupo. Nunca ficou sabendo que Diego comprava, era feito uso em conjunto. Acredita que conhece Gabriel. Não sabe se Diego e Gabriel tinham relacionamento. Sabe que Diego já respondeu processo por tráfico há um ano. Não sabe dizer a quanto tempo Diego comprava entorpecentes para dividir. Entrou no grupo em fevereiro. Ficou sabendo que Diego fazia uso do celular do Marcel na outra prisão (mídia).

O informante Gustavo Ygor Amores Fernandes disse que é amigo íntimo de Diego. Frequenta a casa de Diego e conhece os pais dele. Marcel é professor, assim como a mãe dele chamada Fabiana. Marcel é chamado pelo nome. Diego tem apelido de "Di" ou "D". Marcel não tem ligações com esses apelidos. Há um grupo e já faz parte. Os amigos compravam maconha em conjunto, era dividido o dinheiro. Faziam um rateio. A droga era dividida entre todos. Diego não traficava. Era mais próximo de Diego. Ficou sabendo da prisão de Diego, nessa época não tinha muito contato com ele. Acabava se dirigindo a Diego quando queria entorpecentes para não ir até as biqueiras. Não sabe como Diego conseguia essas drogas. Conseguia drogas por meio do grupo. Fazia parte desse grupo. Quando chegava a droga de qualidade, todo mundo aprovava. Variava de dez a quinze dias. Participou algumas vezes. Não sabe dizer quando o grupo começou, comprou a última vez no final do ano passado. Sabe quem é

Gabriel. Diego e Gabriel são amigos e andavam juntos na época de escola. A arrecadação de dinheiro era feita de forma conjuntava, o pagamento era variado em favor de certas pessoas. Para conseguir a droga teria que pagar (mídia).

Passo a analisar separadamente as imputações envolvendo os acusados Diego e Marcel.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

Pelo que se verifica da prova oral e documental produzida, agentes públicos foram até a residência do acusado Diego cumprir mandado de busca e apreensão. Foram localizados no quarto dele dois recipientes de vidro contendo haxixe e maconha, assim como cigarros artesanais de maconha, um dichavador, uma balança digital e uma carteira contendo dinheiro.

Com autorização escrita de Diego (fls. 38), os telefones celulares apreendidos foram submetidos à análise, havendo intensa comercialização de maconha e haxixe por parte de Diego, em conformidade com o relatório de investigação de fls. 41/50, devidamente acompanhado de fotografias.

Do teor do relatório de investigação de fls. 41/50, extrai-se a seguinte passagem criminosa envolvendo o acusado Diego:

“Na foto 01, é exibido um print de uma conversa do aplicativo de mensagens Whatsapp entre Diego, vulgo “DI” e um indivíduo ainda não identificado, o qual se vale do telefone (19) 1997419-4701, onde este último solicita a Diego vulgo “DI” a droga conhecida como maconha, porém o mesmo diz que também pode ser “DRY”, que é a droga conhecida como haxixe, droga esta que é produzida a partir da maconha onde tem multiplicado o seu poder alucinógeno. Diego responde por áudio que falará com os parceiros, ou seja, com seus amigos traficantes, e em seguida passa o contato de um indivíduo, também ainda não identificado, dizendo que ele “consegue soltar pra vc” conforme foto 02, ou seja fornecerá as drogas para ele, essas conversas se deram nos dias 01 e 02 de janeiro de 2022 (fls. 41, grifo nosso).

Mais diálogos envolvendo o tráfico de drogas praticado pelo acusado Diego foram colhidos:

Os diálogos seguem e já no dia 7 de março de 2022, o indivíduo não identificado que se vale do número do telefone (19) 1997419-4701, procura novamente por Diego vulgo “DI” perguntando se aconteceu algo com o amigo, ou seja o traficante que Diego passou o contato, uma vez que ele não responde mais suas mensagens. Diego responde dizendo “salve meu mano, tem DRY aqui”, ou seja, Diego tem a droga conhecida como HAXIXE, o interlocutor pergunta quanto? E ainda diz “quero sim”, Diego pergunta se ele precisa para o dia em questão, ou seria para o próximo dia, onde o interlocutor responde que queria para hoje. Nas fotos 05 e 06 são exibidos os diálogos das tratativas a respeito do valor de venda, o qual foi acertado ao valor de R\$ 50,00 o grama, sendo a quantia de 2 gramas, totalizando o custo de R\$ 100,00, no áudio Diego diz que entregará a droga em uma praça próximo ao Mister Titas, o qual o interlocutor diz ser atrás de sua casa e ao lado de sua sogra.” (fls. 42/43, grifo nosso).

As mensagens relacionadas ao tráfico de entorpecentes não param por ai e mais detalhes são extraídos dos telefones celulares do acusado Diego:

“Nas fotos 08 e 09, são exibidos prints onde dizem que estão chegando ao local onde a droga será entregue, o interlocutor ainda não identificado que vai comprar a droga diz ter chegado ao local e que está em um Citroën C3 da cor branca, diz ainda que está fora do carro. Vale salientar que a droga apreendida hoje nos autos, é a mesma droga das tratativas acima.” (fls. 45, grifo nosso).

Também foram colhidas outras mensagens envolvendo o acusado Diego e "Carlin Big", denotando que o réu é fornecedor de maconha e haxixe para tal pessoa, com prints de grandes porções de haxixe, havendo indicação de gramas e o respectivo preço da droga (cf. fls. 46/50 - 10 gramas ao valor de R\$ 42,00 o grama; 20 gramas ao valor de R\$ 40,00 o grama; 50 gramas ao valor de R\$ 39,00 o grama; 100 gramas ao valor de R\$ 38,00 o grama).

Desse modo, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado ao acusado Diego, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (maconha e haxixe), a investigação criminal conduzida pela Polícia Civil (relatórios de investigação), as circunstâncias da prisão, petrechos encontrados no seu quarto e as trocas de mensagens (prints de conversas) extraídas dos telefones celulares de Diego, assim como a prova oral colhida na fase do contraditório, tudo a aponta-lo como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).



Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão, da investigação conduzida pela Polícia Civil e das mensagens captadas nos telefones celulares do acusado Diego.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância. (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A conduta perpetrada pelo réu Diego amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Não se cogita em desclassificar para a figura prevista no parágrafo 3 do artigo 33 da Lei de Drogas, que assim dispõe: "Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem".

É fato que a conduta de Diego não se limitou a oferecer drogas a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Anote-se que o acusado sequer conseguiu explicar o teor das mensagens extraídas do seu telefone celular quando interrogado judicialmente, muitas delas indicando valores monetários, chegando a afirmar que desconhecia algumas conversas mencionadas pela Promotora de Justiça em sua denúncia e seus respectivos autores.

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos, de modo que é de rigor a condenação do acusado Diego no delito de tráfico.

No tocante ao corréu Marcel, analisadas as provas reunidas nos autos, verifica-se que o conjunto probatório reunido sob o crivo do contraditório é insuficiente para embasar eventual sentença penal condenatória, em que pese a existência de provas robustas quanto ao corréu Diego, filho de Marcel.

Veja-se que os elementos colhidos na fase judicial não demonstraram certeza acerca da eventual participação do corréu Marcel nos crimes de tráfico e associação cometidos pelo filho Diego, uma vez que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nenhum entorpecente e petrecho foram localizados em seu poder.

As provas carreadas aos autos indicam que o corréu Marcel não tinha ciência dos crimes cometidos por Diego, o que restou corroborado pelo relato dos policiais civis ouvidos em Juízo, não havendo nos autos efetiva prova de que o acusado Marcel eventualmente praticava a traficância em conjunto com o descendente.

Demais disso, Marcel conseguiu dar explicações satisfatórias a respeito das mensagens relacionadas ao tráfico de drogas localizadas no seu telefone celular quando interrogado judicialmente, não hesitando em cooperar com a apuração dos fatos delituosos.

Muito embora os policiais civis tenham trazido informações de suspeitas acerca do envolvimento do corréu Marcel, o que motivou inclusive a expedição de mandado de busca e apreensão na sua residência, não há provas seguras nos autos o incriminando, destacando-se que nenhuma droga foi encontrada com Marcel.

Destarte, não havendo prova suficiente de que o corréu Marcel efetivamente seria o detentor da droga apreendida, não tendo sido comprovada nos autos a efetiva traficância de sua parte, não há como amparar-se eventual condenação criminal, diante do princípio do in dubio pro reo.

Artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006

Para que se perfectibilize o crime de associação para o tráfico, à guisa da jurisprudência dominante, é necessária a comprovação de um elo estável e duradouro a vincular todos os agentes, de modo a tornar transparente a existência de uma verdadeira associação.

Explica Guilherme de Souza Nucci no tocante ao crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06:

“Associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes (...) Sob outro aspecto, a associação criminosa há de ser estável e permanente. Do contrário, seria somente um concurso de pessoas (...) (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, v. 1. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

O saudoso Luiz Flávio Gomes complementa:

“A consumação, que se dá com a formação da *societas criminis*, protraí-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente). Como já alertado acima, não há necessidade de que algum dos delitos de tráfico venha a ocorrer, desde que demonstrado que a associação de pessoas continha um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

No caso em discussão, a existência do elo estável e duradouro restou cabalmente descortinada pelas provas arregimentadas, conforme acima pormenorizado quando da análise do crime de tráfico envolvendo o acusado Diego.

É da inicial acusatória que policiais civis, por meio de autorização do próprio réu Diego, obtiveram acesso ao teor das conversas mantidas pelo acusado via aplicativos de mensagens. O relatório de investigação às fls. 41/50 aponta diálogos travados por Diego com pessoas interessadas na aquisição de maconha e haxixe, cujo teor já foi reproduzido acima quando da análise do crime de tráfico de entorpecentes, com conversas mantidas entre 01 e 02 de janeiro de 2022, 31 de janeiro de 2022 e 07 de março de 2022, culminando com a prisão do réu em 09 de março de 2022, ou seja, por quase três meses perdurou no mínimo a associação delitiva.

Os diálogos extraídos dos dois relatórios de investigação juntados (fls. 41/50 e 51/71) revelam uma associação estável e duradoura para a venda ilícita de entorpecentes, ficando o réu Diego responsável pelo fornecimento das substâncias proibidas a compradores, que mantinham conversas com ele para efetuarem a aquisição e retirada dessas drogas.

Não bastassem as conversas constantes nos relatórios de investigação, também há imagens de entorpecentes comercializados por parceiros do acusado Diego (cf. relatório de investigação de fls. 51/71), o que desencadeou o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, com resultado positivo para encontro de drogas, dinheiro e petrechos utilizados na traficância ilícita, no interior do quarto do acusado.

A conduta do artigo 35 da Lei de Drogas vem representada pelo verbo “associar-se”, que significa agregar-se, unir-se. O dispositivo requer que duas ou mais pessoas se associem para o fim de, reiteradamente ou não, praticar os delitos dos artigos 33, caput e § 1º, e 34. Exige-se um mínimo de estabilidade e não um mero concurso de agentes.

A respeito do tema, cito os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição. Inviabilidade. Quadro robusto e coeso a demonstrar autoria e materialidade delitiva. Inviabilidade do recurso em liberdade diante de condenação. Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal. Redução da pena. Possibilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001023-23.2020.8.26.0602; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021).

"Associação para o Tráfico de Drogas – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Argumentação referente ao mérito dos fatos – Ausência de demonstração de prejuízo ao direito de defesa – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura que demonstrou, à sociedade, o vínculo associativo e a estabilidade existente entre os envolvidos – Condenação bem decretada – Penas-base exasperadas em função das circunstâncias do crime – Reprimendas mantidas – Regime fechado necessário devido a gravidade concreta do delito – Estreita relação com facção criminosa – Preliminar Rejeitada e Recursos improvidos." (TJSP; Apelação Criminal 0007090-75.2016.8.26.0268; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021).

"Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação para esse fim. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Provas do vínculo associativo. Condenações mantidas. Pena e regime bem fundamentados. Reconhecimento da confissão espontânea em relação ao réu Wesley. Impossibilidade. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividades criminosas. Réu Wesley reincidente. Regime inicial fechado mantido. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recursos improvidos". (TJSP; Apelação Criminal 1500995-07.2019.8.26.0540; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021).

Vale, neste momento, uma observação respeitante à qualidade da prova para tipificação do crime em testilha. Diferentemente do esperado pela Defesa de Diego, é evidente que a prova da associação para o tráfico não se dá da mesma maneira que aquela própria do pequeno traficante, do indivíduo que vende entorpecente como forma de sustentar seu próprio vício.

Trata-se de um vínculo associativo, bastando o ajuste para o propósito comum de mercanciar entorpecentes, independentemente dos motivos de cada agente, individualmente. Vale dizer, desinteressa se o indivíduo mantém o liame para alimentar seu vício com a venda ou se seu interesse imediato é o lucro. O que importa é a existência, como dito, de um elo entre os comportamentos enveredados pelos agentes na forma de explorar a narcotraficância, o que constatado nos autos pelos fundamentos já indicados.

No tocante ao corréu Marcel, como não há prova suficiente de que seria o detentor da droga apreendida, não havendo prova de associação de sua parte, não há como amparar-se eventual condenação criminal no crime de associação, diante do princípio do in dubio pro reo.

Por fim, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado Diego tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19. Os delitos imputados foram cometidos em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de

Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)". (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

Desse modo, demonstrada a procedência das imputações unicamente contra o acusado Diego, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes e nem atenuantes na segunda fase.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

A causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser aplicada. A configuração do crime de tráfico em conjunto com o delito de associação é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. GRAVAÇÃO MAGNÉTICA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 405, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ. 5. Fixada a reprimenda em quantum superior a oito anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e a inviabilidade da concessão do benefício da substituição das penas, a teor do que dispõe o art. 44, I, do mesmo código. 6. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INQUIRição DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA. INVERSÃO DA ORDEM. CARTA PRECATÓRIA. INTERROGATÓRIO DO RÉU. IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. ALEGAÇÕES DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ACRÉSCIMO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RAZOABILIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006